

1506070-87.2019.8.26.0132

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Carlos Pinheiro de Freitas

Comarca: Catanduva

Foro: Foro de Catanduva

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/03/2022

... tem o significado de que toda e qualquer união destinada à prática do tráfico ilícito de drogas caracterize o delito de associação para o mesmo tráfico, pois a união, o acordo de vontades destinado ao cometimento do comércio ilícito, sem a comprovação de uma vontade distinta, organizada no sentido de constituição de uma associação voltada ao mesmo tráfico (vontade, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Catanduva

Foro de Catanduva

1ª Vara Criminal

Parque das Américas, 55, Catanduva-SP - cep 15800-032

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1506070-87.2019.8.26.0132 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1506070-87.2019.8.26.0132

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2357165/2019 - DEL.INV.GER. CATANDUVA, 8987738 - DEL.INV.GER. CATANDUVA, 554/19/121 - DEL.INV.GER. CATANDUVA, 2357165 - DEL.INV.GER. CATANDUVA, 554/19/121 - DEL.INV.GER. CATANDUVA, 2357165 - DEL.INV.GER. CATANDUVA, 554/19/121 - DEL.INV.GER. CATANDUVA, 2357165 - DEL.INV.GER. CATANDUVA, 554/19/121 - DEL.INV.GER. CATANDUVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

REGINALDO SANCHES e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonio Carlos Pinheiro de Freitas

Vistos.

REGINALDO SANCHES e CAROLINE CRISTINE PAES PINTO, qualificados, respectivamente, às págs. 6 e 4, foram denunciados como incurso nos arts. 33, "caput", e 35, "caput", ambos da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, pela prática dos seguintes fatos delituosos:

"No dia 10 de dezembro de 2019, às 15h30min, na Rua São Lourenço, 545, Jardim Bom Pastor, nesta cidade e Comarca de Catanduva/SP, os denunciados se associaram para o

fim de praticar o crime de tráfico de drogas e, nesta qualidade, guardavam 13 (treze) pinos de cocaína e 88 (oitenta e oito) pinos de "crack", totalizando o peso bruto 73,2 gramas, drogas que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fl. 11, laudo de constatação de fls. 13/14 e exame químico toxicológico de fls. 68/72.

Segundo se apurou, os policiais militares receberam denúncias de populares, no sentido de que, um casal estava se dedicando ao tráfico ilícito de drogas na residência situada no local dos fatos. Em diligência, constatou-se que a porta estava aberta e os denunciados estavam no interior do imóvel, sendo que guardavam, embaixo do botijão de gás, uma pochete, na qual havia 88 (oitenta e oito) pinos de "crack" e 13 (treze) pinos de cocaína. Ainda, REGINALDO trazia consigo a quantia de R\$35,00 (trinta e cinco reais) em dinheiro.

Informalmente para os policiais, os denunciados confessaram que estavam se dedicando ao tráfico ilícito de drogas, sob a justificativa de que passavam por necessidades. Já na Delegacia de Polícia, os denunciados negaram a prática delitiva.

CAROLINE CRISTINE já havia sido presa dias antes pela prática do mesmo crime e é companheira de REGINALDO, estando ambos associados para a mercancia ilícita.

Ante o exposto, denuncio REGINALDO SANCHES e CAROLINE CRISTINE PAES PINTO como incurso nas sanções do artigo 33 e do artigo 35, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69, do CP, e requeiro que sejam intimados para apresentarem defesa prévia e, depois de recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo legal, citando-se os acusados para a audiência de instrução e julgamento, nos moldes do art. 56 da Lei 11.343/06, oportunidade na qual serão interrogados, serão ouvidas as testemunhas abaixo arroladas, como também as da defesa, serão apresentadas sustentações orais pelo parquet e pela defesa, até final decisão condenatória, na forma do rito especial previsto na Lei 11.434/06.

Os acusados foram presos em flagrante delito no dia fatos e, atualmente, REGINALDO permanece em prisão domiciliar (págs. 372/374). A acusada foi posta em liberdade em data posterior (págs. 202/203).

Citados e notificados (págs. 127 e 139), os acusados apresentaram as defesas prévias de págs. 112/113 e 114/117.

A denúncia de págs. 79/80 foi recebida em 26 de fevereiro de 2020 (págs. 140/141). Durante a instrução criminal, foram ouvidas duas testemunhas comuns e, por último, interrogados os acusados (audiência de págs. 397/398).

Na fase do art. 402, do Código de Processo Penal, nada foi requerido (pág. 398). Em seu memorial de págs. 421/427, o Ministério Público pleiteia a condenação, entendendo provados os fatos narrados na denúncia.

A Defesa de REGINALDO, a seu turno, às págs. 439/447, pugna pela absolvição, alegando insuficiência de provas.

Por último, a Defesa de CAROLINE CRISTINE requer a desclassificação da conduta para a norma prevista no art. 28, "caput", da mesma Lei.

Houve instauração de incidente de dependência químico-toxicológica em relação à acusada (págs. 177/179), com laudo pericial às págs. 410/412.

É relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A acusação é parcialmente procedente, pois, conforme adiante será exposto, cometeram os acusados somente o delito de tráfico ilícito de drogas.

A materialidade de tal delito está provada por intermédio do auto de exibição e apreensão de págs. 11 (referente a 13 (treze) pinos de "cocaína" e 88 (oitenta e oito) pinos de "crack" e R\$35,00, em dinheiro) e dos laudos de exame químico-toxicológico de págs. 13/14 e 64/67, estes demonstrando que as substâncias apreendidas se tratavam de drogas.

A autoria, quanto ao tráfico ilícito de drogas, também é certa, incontroversa.

Na fase policial (págs. 4), a ACUSADA negou a prática delitiva, alegando que as drogas descritas nos autos não foram encontradas em sua casa. Tinha em sua posse

somente um pino de "crack", destinado ao seu próprio consumo.

O ACUSADO também negou a prática da infração penal durante o inquérito policial (pág. 6), alegando que havia feito um serviço de pintura para sua mãe, em razão do que ganhou a quantia de R\$50,00 (cinquenta reais), com a qual comprou dois sacos de argamassa, tendo lhe sobrado a importância de R\$31,00 (trinta e um reais). Estava colocando piso na casa no momento em que os policiais ali chegaram. A acusada, sua amásia, tinha em sua posse somente dois pinos de "crack", pois era usuária da substância. Negou envolvimento com tráfico de drogas. Não havia outros entorpecentes no local.

Em Juízo (gravação referente à audiência de págs. 397/398), a ACUSADA alegou que a droga era toda sua e que seu marido (acusado) nada tinha a ver com isso. Usava a droga e também vendia uma parte da substância. Seu marido não sabia que a interrogada guardava as drogas dentro de casa. Realmente confessou a prática do crime aos policiais. Não ouviu se seu marido confessou a prática delitiva aos policiais. O acusado estava assentando pisos na residência quando os policiais ali chegaram. O imóvel era da mãe do acusado e foi ela quem deu o dinheiro para que ele comprasse o material para reformar o local. O acusado trabalhava de pintor e, em tal condição, realizou um serviço de pintura para a mãe dele e ela, em troca, deu dinheiro a ele, o qual foi usado para comprar argamassa para que o piso fosse assentado no local. O acusado recebeu a quantia de R\$50,00 (cinquenta reais) da mãe dele. Deixou a droga escondida na residência. Usa drogas desde os 16 (dezesesseis) anos de idade, porém, embora tenha tentado, não conseguiu tratamento. Nada tem contra os policiais que atenderam a ocorrência.

O ACUSADO, por sua vez (gravação referente à audiência de págs. 397/398), negou completamente a prática da infração penal, alegando que não tinha ciência da existência das drogas na casa. O imóvel em que os fatos ocorreram era da mãe do interrogando. Morava no local no dia dos fatos, em companhia da acusada, sua esposa. A casa foi cedida para que o interrogando e sua esposa ali morassem. Não estava praticando tráfico de drogas. Não confessou a prática do crime aos policiais. Estava instalando pisos no local naquele dia. Trabalha como pintor e, na ocasião dos fatos, realizou serviços de pintura para sua mãe, em razão do que recebeu dela a quantia de R\$50,00, com o qual comprou dois saquinhos de argamassa. Havia apenas dez peças de pisos para instalação. Começou a instalar os pisos no imóvel, momento em que policiais ali compareceram. Os policiais não tinham mandado e nem lhe pediram licença para ingressar na casa. Um dos policiais lhe disse que "daria uma olhada" na casa, com o que o interrogando concordou. Deixou os policiais olharem a casa. Um dos policiais começou a vistoriar o quarto da residência, enquanto que um outro policial ficou ao lado do interrogando e na cozinha ali existente. O policial que estava no quarto retornou minutos depois e mandou o interrogando e a acusada entrarem no veículo policial. Não sabia que sua esposa se encontrasse traficando drogas no local. Nada tem contra os policiais que depuseram nos autos. Já viu a acusada usando drogas. Ela até sumia da residência de madrugada, motivo pelo qual o interrogando ia à delegacia pedindo providências. A acusada usava "crack".

A confissão parcial da acusada e a negativa de autoria apresentada pelo acusado, contudo, devem ceder diante das produzidas pela acusação.

É que o POLICIAL MILITAR CLAUDEMIR APARECIDO BASSI (gravação referente à audiência de págs. 397/398) disse ter recebido denúncias de populares de que um casal que residia na rua São Lourenço, nº 545, estava traficando drogas, razão pela qual foi ao local, ocasião em que, estando a porta do imóvel aberta, visualizou os acusados dentro da residência. Em buscas, localizou R\$35,00 em poder do acusado e o policial Braguini encontrou, sob um botijão de gás, as drogas descritas na denúncia. Os acusados confessaram a traficância e disseram que estavam vendendo drogas por estar passando necessidades. Não conhecia os acusados. Indagado se os acusados disseram o tempo em que estavam traficando, disse apenas que eles confessaram, no dia dos fatos, que estavam traficando drogas em razão de necessidades. A casa era humilde e normal. Não se recorda se o acusado estava mexendo com assentamento de piso no momento dos fatos. Não se recorda se os R\$35,00 encontrados com o acusado estavam em notas fracionadas. Não havia denúncias anteriores de ocorrência de tráfico de

drogas no local contra os acusados.

O TAMBÉM POLICIAL MILITAR RAFAEL BRAGUINI DE CAMARGO (gravação referente à audiência de págs. 397/398) depôs no mesmo sentido do outro policial. Também não conhecia os acusados até então. A casa era pobre, não tinha muitos móveis. O acusado estava mexendo com pisos no momento dos fatos. Estava havendo assentamento de piso no imóvel naquele momento. Os acusados disseram que moravam no local. Os acusados, segundo lhe informaram, eram amasiados.

Diante das apreensões realizadas e dos relatos dos agentes da lei, a prova demonstra, de forma segura, que os acusados, agindo em conjunto, se encontravam praticando a mercancia ilícita na ocasião descrita na denúncia, pois, após recebimento de denúncias de que um casal estava praticando tráfico de drogas na residência descrita nos autos, policiais para lá se dirigiram e localizaram, nas dependências do imóvel, treze pinos plásticos de "cocaína" e oitenta e oito de "crack", prontos para venda e suficientes, portanto, para fornecimento a inúmeras pessoas, e R\$35,00 (trinta e cinco reais), em dinheiro (resultante da venda da substância ilícita, conclusão possível diante das circunstâncias dos autos), ocasião em que ambos confessaram, no local da prisão, que de fato vendia as substâncias ilícitas.

Outro indicativo da ocorrência de prática da mercancia ilícita por parte da acusada é a variedade das substâncias ("cocaína" e "crack"), pela qual se nota que o comércio ilícito tinha o objetivo de atingir um número maior de consumidores, usuários de mais de um tipo de droga, os quais, no mesmo local, encontravam substâncias de naturezas diversas; quem negocia drogas de vários tipos visa, obviamente, não perder venda, na medida em que atrai, para um mesmo local, usuários de substâncias de naturezas distintas e, com isso, normalmente alcança um resultado maior no volume das vendas.

A atitude dos acusados é típica de quem pratica a mercancia ilícita e as diligências, da forma como se deram, só vieram a confirmar a denúncia ocorrida no dia dos fatos, no sentido de que ambos vendiam drogas na residência já mencionada. Cometeram os acusados, assim, o delito de tráfico ilícito de drogas que lhes foi imputado na denúncia.

A negativa de autoria de Reginaldo e a confissão apenas parcial de Caroline Cristine, permaneceram totalmente isoladas nos autos e, portanto, não merecem acolhimento.

O fato de a acusada também ser usuária de substâncias entorpecentes (conforme conclusão contida no laudo pericial de 410/412) não permite, por si só, eventual desclassificação do delito, pois nada impede que o fornecedor de entorpecentes também faça uso das mesmas substâncias, caso em que a figura do uso é absorvida pela norma contida no artigo de lei por último mencionado.

Confira-se:

"Traficante viciado

Nada impede que responda como traficante. Nesse caso, aplica-se a norma do art. 12, absorvido o delito do art. 16 desta Lei. Nesse sentido: RT 515:466, 517:368 e 380, 555:380, 585:311 e 595:408; RJTJSP, 101:498 e 114:482; JTACrimSP, 64:38; TJRS, RCrim 1.342, RF 283:322; TJMT, ACrim 212.180, RF , 282:403; TJRS, ACrim 691069488, RJTJRS , 154:141; TJPR, ACrim 342/88, PJ, 29:241; stf, HC 69.806, 1a. Turma, rel. Min. Celso de Mello, RT 701:401 e RTJ, 151:155. Tanto é que o art. 11 desta Lei reza: 'Ao dependente que, em razão de qualquer infração penal, for imposta pena...' (grifo nosso)" (conforme Damásio E. de Jesus, Lei Antitóxicos Anotada, São Paulo : Saraiva, 4a. ed., 1999, p. 21).

Tal jurisprudência, embora se refira à lei antiga, aplica-se, obviamente, à lei atual.

Quanto à força probante do probante dos relatos dos agentes da lei colhidos durante a instrução criminal, sabe-se que os depoimentos de policiais, não estando contrariados por outros elementos concretos de prova existentes nos autos, têm a mesma validade dos relatos de toda e qualquer pessoa que se apresente como testemunha.

Analisando a questão, a jurisprudência assim já se pronunciou:

"Os testemunhos de policiais devem ser recebidos com a mesma credibilidade que se

reconhece em qualquer outro cidadão" (JTACrim, 10:138).

"Os funcionários da Polícia merecem, em seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador" (RT, 668:275).

As regras de experiência comum permitem a conclusão de que pessoas da comunidade que não integram os quadros policiais dificilmente se prontificam a depor contra traficantes de drogas, pois estes normalmente são pessoas perigosas e de personalidade violenta e voltada para a prática de crimes e que causam, portanto, medo e temor às pessoas de bem, as quais, por temerem represálias, não se apresentam aos agentes do Estado para depor como testemunhas.

No que pertine à infração penal de associação para o tráfico ilícito de drogas, por outro lado, a prova não é suficiente para a condenação.

Para a caracterização do delito de associação para o referido tráfico, exige-se que a vontade de se associar seja separada da vontade necessária para a prática do crime visado, sendo as vontades, portanto, distintas.

Nesse sentido, cito as seguintes jurisprudências, trazidas por Renato Marcão em sua obra Tóxicos (São Paulo : Saraiva, 6ª. ed., 2009, p. 256 e 260):

"O delito de associação para o tráfico não pode, de forma alguma, ser comparado a um mero concurso de agentes, sendo necessária para sua caracterização a existência de um vínculo associativo, em que a vontade de se associar seja separada da vontade à prática do crime visado" [TJSP, Ap. 295.901-3/1-00, 6ª Câmara, j. 6-4-2000, rel. Des. Barbosa Pereira, RT 779/571].

"Configura-se com o animus associativo, isto é, um ajuste prévio, no sentido da formação de um vínculo associativo de fato, uma verdade, em que a vontade de se associar sobrepaire, mas coexista com a vontade necessária à prática do crime visado" [TJSP, Ap. Crim. 210.425-3/7, 4ª Câmara, j. 10-6-1997, rel. Des. Bittencourt Rodrigues, RT 745/539].

"Para não confundir-se com o mero concurso de agentes, a melhor interpretação reclama à sua incidência o ajuste prévio e um mínimo de organização, seja embora na preparação e no cometimento de um só delito de tráfico ilícito de drogas, hipótese que a sentença julgou provada" [STF, ROHC 75.236-5/AM, 1ª T., j. 3-6-1997, rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJU de 1º-8-1997, RT 749/584]" (Tóxicos, São Paulo : Saraiva, 6ª edição, 2009, p. 256 e 260).

Na mesma linha, leciona Damásio de Jesus:

"Elementos subjetivos do tipo

O primeiro é o dolo, vontade consciente de concretizar a associação. Há um segundo elemento subjetivo do tipo, contido na expressão 'para o fim de praticar' [crimes dos arts. 33, caput e § 1º, 34 e 36 desta Lei]. Sem a finalidade especial o fato é atípico. Nesse sentido: RT 532:381. Assim, a figura típica exige a presença do ânimo associativo, i. e., 'de um ajuste prévio no sentido da formação de um vínculo associativo, uma verdadeira societas sceleris, em que a vontade de se associar seja separada da vontade necessária para a prática do crime visado' [Vicente Greco Filho, Tóxicos, cit., 1979, p 104]" (Lei Antidrogas Anotada, São Paulo : Saraiva, 9ª ed., revista e atualizada, 2009, p. 160, sem grifos na parte final do texto).

A elementar "reiteradamente ou não", prevista no art. 35, "caput", não tem o significado de que toda e qualquer união destinada à prática do tráfico ilícito de drogas caracterize o delito de associação para o mesmo tráfico, pois a união, o acordo de vontades destinado ao cometimento do comércio ilícito, sem a comprovação de uma vontade distinta, organizada no sentido de constituição de uma associação voltada ao mesmo tráfico (vontade, no caso, presente na elementar "associarem-se"), caracteriza mero concurso de agentes (CP, art. 29, "caput") destinado à realização de um dos crimes previstos nos arts. 33, "caput" e § 1º e 34, ambos de tal Lei, hipótese em que somente um destes (delitos previstos nos arts. 33, "caput" e § 1º, e 34) se consuma; e, para a caracterização da infração penal de associação para o tráfico, exige-se, consoante já exposto, um dolo distinto, separado do cometimento em si do tráfico ilícito de drogas, ainda que não haja reiteração de conduta, sendo este o significado da primeira elementar ora mencionada ("reiteradamente ou não").

São situações distintas, portanto, sendo o ato de se associar para o tráfico, o qual exige prova concreta (separada), uma coisa, e o de praticar efetivamente o tráfico ilícito, outra; caso dois ou mais agentes, por exemplo, atuem em conjunto para vender drogas, sem a constituição de uma associação destinada ao comércio ilícito, ocorre mero concurso de agentes para o cometimento do crime previsto no art. 33, "caput", e, na hipótese de além de a venda em si da substância ilícita, eles estabelecerem um vínculo associativo, organizado, distinto, destinado às vendas, a conduta criminosa descrita no art. 35, "caput", também se caracteriza. Aliás, sendo o momento consumativo do crime de associação para o tráfico a ocasião em que os agentes se associam para a prática dos delitos previstos nos arts. 33, "caput" e § 1º, e 34, ambos de tal Lei (conforme lição de Damásio de Jesus sobredita), o crime previsto no art. 35, "caput", do mesmo Diploma Legal, pode ocorrer sem que o agente pratique efetivamente os crimes descritos nos dispositivos de lei supramencionados (arts. 33, "caput" e § 1º, e 34).

Quanto ao momento consumativo do crime, ensina Damásio de Jesus:

"Momento consumativo

Ocorre com a associação. Na expressão de Italo Galli, no 'momento associativo' [JTACrimSP, 54:351]. Nesse sentido: RT, 634:277; RJTJSP, 72:316; STJ, REsp 3.943, 5ª. Turma, DJU, 5 nov. 1990, p. 12437, independentemente de eventual prática dos crimes pretendidos pelo bando. Nesse sentido: RJTJSP, 69:348. Sob esse aspecto, trata-se de crime formal ou de consumação antecipada, natureza extraída do elemento subjetivo do tipo 'para o fim de...'. Nesse sentido: RJTJSP, 69:348" (op. cit., p. 161/2).

No caso presente, no entanto, não ficou comprovada a existência de uma vontade distinta, por parte dos acusados, no sentido de constituição de uma associação (é dizer, de um vínculo associativo) direcionada à prática do delito de tráfico ilícito de drogas, porquanto as diligências policiais limitaram-se ao momento dos fatos e ao dia da prisão e, pelos depoimentos dos policiais, referido vínculo associativo não ficou, portanto, provado.

Para a comprovação do crime de associação para o tráfico ilícito de drogas, são necessários elementos concretos de prova no sentido de existência do referido vínculo (associativo) entre os agentes, tais como interceptações telefônicas anteriores ou em andamento, pedidos de busca e apreensão anterior, realizações de campanhas em datas anteriores, apreensão de eventual documentação comprobatória e até mesmo apreensão, em data anterior, de drogas pertencentes aos investigados, não bastando, desse modo, meras informações genéricas e anônimas dando conta de que os mesmos agentes/investigados vinham praticando a mercancia ilícita.

Ademais a doutrina e a jurisprudência, quase que de forma unânime, exigem a comprovação de dois requisitos para a caracterização de delito de associação para o tráfico ilícito de drogas, sendo eles estabilidade e permanência, os quais não ficaram comprovados na conduta dos acusados.

Sobre a necessidade de prova de tais requisitos (estabilidade e permanência) na espécie, segue o posicionamento da jurisprudência:

"Apelações do Ministério Público e de um dos réus - Tráfico de entorpecente e associação para tal delito. Insurgência ministerial que se restringe à absolvição dos réus da associação - Ausência de estabilidade e de ânimo subjetivo -

Precedentes - Absolvição que se mantém. Defesa que busca a absolvição, desclassificação da conduta para uso pessoal ou redução das penas - Acusados apanhados com 18 pinos de cocaína (11,23g) - Materialidade e autoria bem demonstradas - Testemunho de agentes policiais, sob o crivo do contraditório, ratificando a prova administrativa - Desclassificação para uso pessoal - Impossibilidade - Finalidade mercantil - Pena mínima reduzida de 1/6, nos termos do § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06, conformada a acusação nesse ponto - Regime fechado - Necessidade. Recursos não providos" (TJ-SP - APL: 00000565820148260417 SP 0000056-58.2014.8.26.0417, Relator: Ivan Sartori, Data de Julgamento: 15/09/2015, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 21/09/2015).

"TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - RÉUS QUE TRANSPORTAVAM E GUARDAVAM 11 PORÇÕES DE MACONHA, PARA FINS DE COMERCIALIZAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM SINTONIA COM O ACERVO PROBATÓRIO, A MERECER CREDIBILIDADE - TRAFICÂNCIA COMPROVADA -

CONDENAÇÕES MANTIDAS. AUSÊNCIA DE PROVAS DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA PARA CARACTERIZAÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE FABRICAÇÃO, PRODUÇÃO, PREPARO OU TRANSFORMAÇÃO DE ENTORPECENTES - CONDUTAS NÃO COMPROVADAS NOS AUTOS - OBJETOS APREENDIDOS QUE SE DESTINAVAM À SEPARAÇÃO E ACONDICIONAMENTO DOS TÓXICOS - ABSOLVIÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 34 DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO MINISTERIAL OBJETIVANDO O AFASTAMENTO DO REDUTOR, PREVISTO NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS PARA O RÉU NIVALDO - POSSIBILIDADE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO" (TJ-SP - APL: 30038922720138260286 SP 3003892-27.2013.8.26.0286, Relator: Willian Campos, Data de Julgamento: 29/10/2015, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 04/11/2015).

No mesmo sentido, preleciona Guilherme de Souza Nucci:

"101. Análise do núcleo do tipo: associarem-se (reunirem-se, juntarem-se) duas ou mais pessoas com a finalidade de praticar (realizar, cometer) os crimes previstos no arts. 33, caput, e § 1.º, e 34 da Lei 11.343/2006. É a associação criminosa específica do tráfico ilícito de entorpecentes. Em nosso entendimento, cuida-se de delito equiparado a hediondo, como os arts. 33 e 34 (antigos arts. 12 e 13 da Lei 6.368/76), pois a associação criminosa tem justamente essa finalidade, vale dizer, o tráfico. Demanda-se a prova da estabilidade e permanência da mencionada associação criminosa. Nesse prisma: STJ: 'O crime do art. 35 da Lei n. 11.343/06 exige que a associação entre os agentes ocorra de forma estável ou em caráter permanente, caracterizando a reunião eventual mero concurso de pessoas. No caso, tendo as instâncias ordinárias, após exame das provas dos autos, constatado a existência de estabilidade e permanência entre o agravante e outros indivíduos, inviável a reversão do julgado ante o óbice constante da Súmula 7/STJ.' [AgRg no AREsp 303.213/SP, 5.ª T, rel. Marco Aurélio Bellizze, DJ 08.10.2013]; 'O tipo previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006 se configura quando duas ou mais pessoas reunirem-se com a finalidade de praticar os crimes previstos nos arts. 33 e 34 da norma referenciada. Indispensável, portanto, para a comprovação da materialidade, o animus associativo de forma estável e duradoura com a finalidade de cometer os crimes referenciados no tipo. II- De outro lado, o delito de associação para o tráfico de entorpecentes é crime autônomo, sendo prescindível para a sua configuração efetiva prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 34 da Lei 11.343/2006.' [REsp 1.113.728-SC, 5.ª T., rel. Felix Fischer, 29.09.2009, v.u.]. TJDF: 'O delito de associação para o tráfico de drogas, estatuído no artigo 35 da Lei n.º 11.343/2006, exige, para a sua caracterização, a associação estável e permanente de dois ou mais agentes, agrupados com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos no artigo 33, caput e § 1.º, e artigo 34 do mesmo diploma legal. assim, diante das provas do animus associativo de caráter estável e duradouro entre o apelante e os codenunciados, inviável o pleito absolutório quanto ao delito de associação para o tráfico, especialmente pelas declarações prestadas pelos policiais, corroboradas pelas interceptações telefônicas.' [Apelação 20100112165299APR, 2.ª Turma Criminal, rel. Roberval Casemiro Belinati, DJ 20.03.2014]. TJSP: 'Acusados que se cooperavam, agindo mutuamente, ainda que eventualmente, na prática do comércio de entorpecentes. Insuficiência de provas - Acolhimento Não configurada a estabilidade e permanência do vínculo subjetivo. Absolvição que se impõe. Recursos defensivos providos.' [Apelação 0029273-41.2010.8.26.0562, 4.ª Câmara Criminal Extraordinária, rel. César Augusto Andrade de Castro, DJ 27.03.2014]. TJMG: 'A atuação das rés em 'societas sceleris', realizando, de forma estável e permanente, um programa delinquencial e praticando crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, especialmente da droga denominada cocaína, dá ensejo à condenação pelo delito tipificado no art. 14 da Lei 6.368/76 [revogada].' [Ap. 1.0324.03.016270-9, rel. Paulo César Dias, 23.11.2004, DJ 25.02.2005]..." (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas - vol. 1, Rio de Janeiro : GEN/Forense, 8.ª edição, revista, atualizada e ampliada, 2014, p. 361/2). Dessa forma, quanto ao tal ponto da acusação, deve militar, em favor dos acusados, o princípio "in dubio pro reo", pelo qual a dúvida favorece o agente. O decreto condenatório, assim, é de rigor somente quanto ao delito de tráfico ilícito de drogas. Passo à dosagem da pena.

a)- Caroline Cristine:

Na primeira fase, levando-se em conta a razoável quantidade de drogas apreendida, suficiente para fornecimento a inúmeras pessoas, e a natureza (alto poder lesivo e viciante) de delas ("cocaína" e "crack"), fixo a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, mínima legal acrescida de 1/6 (um sexto).

O art. 42, da mesma Lei, determina o aumento da pena em razão da quantidade e natureza das drogas.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes e/ou atenuantes a serem consideradas.

Deixo de reconhecer a atenuante genérica da confissão espontânea, vez que a confissão da acusada foi apenas parcial, na medida em que, de forma totalmente contrária à prova, negou o envolvimento do outro acusado na prática criminosa, com o que seu relato não pode ser considerado sincero, espontâneo; ademais, a confissão parcial da acusada não foi considerada como elemento de convicção nesta sentença, porquanto, para a prova da autoria, foram considerados, apenas e tão-somente, as apreensões realizadas, os relatos dos policiais militares, a denúncia de existência de tráfico ilícito de drogas no local dos fatos e as circunstâncias da prisão, hipótese em que incabível a aplicação da Súmula 545 do STJ, a qual dispõe que "Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal."

Na terceira fase, tendo em vista que a acusada não registra antecedentes e não havendo comprovação de que ela viesse se dedicando às atividades criminosas ou integrando organização criminosa, reduzo a pena em 2/3 (dois terços), para 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

A acusada não era conhecida nos meios policiais (depoimentos de ambos os policiais), a droga apreendida não era de expressiva quantidade e a quantia localizada era de ínfimo valor, caso em que não pode ser descartada a hipótese de ela ser mera traficante ocasional, não havendo comprovação, portanto, de eventual dedicação às atividades criminosas.

Não há provas no sentido de que a acusada integrasse organização criminosa ou se dedicasse às atividades criminosas, vez que não ficou esclarecido, por exemplo, qual a organização criminosa que eventualmente atuava no local dos fatos, quem a integrava, quais as divisões de tarefas e qual eventual participação da acusada nela, não havendo, portanto, prova segura e conclusiva a respeito, situação em que deve ser aplicado, em favor do agente, o princípio "in dubio pro reo".

Abonando tal entendimento:

"O afastamento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 exige fundamentação idônea. A ausência de provas do envolvimento em atividades criminosas ou da participação em organizações criminosas deve ser interpretada em benefício do acusado e, por conseguinte, não é suficiente para afastar a aplicação da causa de redução de pena. Incidência do princípio da presunção de inocência e da regra do in dubio pro reo (STF, HC 103225 - RN, 2ª T., rel. Joaquim Barbosa, 11.10.2011, v.u., julgado citado por Guilherme de Souza Nucci em Leis Penais e Processuais Penais Comentadas - volume 1, Forense : Rio de Janeiro, 8ª edição, revista, atualizada e ampliada, 2014, p. 349).

Ainda na terceira e última fase, tendo em vista a semi-imputabilidade da acusada (laudo pericial de págs. 410/412), reduzo, com fulcro no art. 46, da mesma Lei, a pena em mais 2/3 (dois terços), para torná-la definitiva em 7 (sete) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 64 (sessenta e quatro) dias-multa.

O valor do dia-multa será o equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em virtude da condição financeira da acusada (consta ser pessoa de baixa condição financeira - informações sobre a vida pregressa de págs. 18).

Diante do novo posicionamento do Colendo Supremo Tribunal Federal (HC nº 118.533, Plenário do STF, j. em 23/06/2016), acolhido, aliás, pela denominada Lei Anticrime (art. 112, § 5º, da Lei de Execução Penal, com redação dada por tal Lei - Anticrime), o crime de tráfico na forma privilegiada, hipótese tratada nos autos,

deixou de ser equiparado a hediondo, razão pela qual, não havendo impedimento legal, o regime inicial de cumprimento da pena será o aberto (CP, art. 3, § 2º, "c").

Também não havendo impedimento legal, substituo a pena privativa de liberdade pelas restritivas de direitos de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo mesmo prazo da pena corporal, cujo local e forma de cumprimento serão fixados na fase de execução, e prestação pecuniária em favor de entidade pública ou privada de destinação social local, no valor equivalente a 1 (um) salário mínimo atual (valor fixado pelo Governo Federal), compatíveis diante da conduta objeto destes autos.

A respeito da possibilidade de fixação de regime inicial aberto e substituição da pena corporal por restritivas de direitos em casos de tráfico privilegiado, trago à cola o seguinte Julgado:

"Tráfico de drogas. Conduta de trazer consigo, para fornecimento a consumo de terceiros, 34 porções de maconha, com peso bruto de 53,3 gramas. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Prisão em flagrante delito. Depoimento dos policiais. Apreensão da droga. Negativa isolada nos autos. PENA. Causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Incidência do redutor máximo por conta da pequena quantidade de entorpecente e das circunstâncias judiciais favoráveis do agente. Não comprovação de que o réu se dedica a atividades criminosas. Concretização em 1 ano e 8 meses de reclusão, mais 166 dias-multa. SUBSTITUIÇÃO da privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Precedente do STF. Fixação do regime aberto. Apelo provido para esses fins" (TJSP, Apelação Criminal nº 0002334-14.2014.8.26.1032, Comarca de Catanduva, 16ª Câmara Criminal, Rel. Otávio de Almeida Toledo, j. em 14/02/2017, v.u.).

No mesmo sentido (possibilidade de substituição da pena corporal por restritivas de direito) também já foi decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no "Habeas Corpus" nº 596.603 - SP (2020/0170612-1), Relator Ministro Rogério Schietti Cruz, j. em 08/09/2020, Sexta Turma.

b)- Reginaldo:

Na primeira fase, levando-se em conta a razoável quantidade de drogas apreendida, suficiente para fornecimento a inúmeras pessoas, e a natureza (alto poder lesivo e viciante) de delas ("cocaína" e "crack"), bem como os maus antecedentes (processo nº 0014847-63.2004.8.26.0132 - págs. 24/25), fixo a pena-base em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, mínima legal acrescida de 1/3 (um terço).

Na referida fração (1/3), foram considerados 1/6 (um sexto) em razão da quantidade e natureza das drogas e 1/6 pelos maus antecedentes do acusado.

O art. 42, da mesma Lei, determina o aumento da pena em razão da quantidade e natureza das drogas.

A condenação referente a tal processo, porém, não é apta para gerar reincidência, porque já superado o lapso temporal previsto no art. 64, I, do Código Penal.

Na segunda fase, não há circunstâncias a serem consideradas.

Tratando-se de maus antecedentes, incabível a causa de redução de pena descrita no art. 33, § 4º, da mesma Lei.

Não havendo outras circunstâncias ou causas de modificação da serem consideradas, torno definitiva a pena em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

O valor do dia-multa será o equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em virtude da condição financeira do acusado (consta ser pessoa de baixa condição financeira - conforme interrogatório judicial e informações sobre a vida pregressa de pág. 15).

O regime inicial de cumprimento da pena, tendo em vista a gravidade do delito, equiparado a hediondo e um dos que mais afetam a paz pública nos dias atuais, bem como os maus antecedentes do acusado (condenação anterior pelo mesmo delito - págs. 24/25), será o fechado, compatível para prevenir e reprovar a infração penal.

Quanto à imposição de regime fechado para a infração penal prevista no art. 33, "caput", da mesma Lei, cito a seguinte jurisprudência:

"Apelações do Ministério Público e de um dos réus - Tráfico de entorpecente e

associação para tal delito. Insurgência ministerial que se restringe à absolvição dos réus da associação - Ausência de estabilidade e de ânimo subjetivo - Precedentes - Absolvição que se mantém. Defesa que busca a absolvição, desclassificação da conduta para uso pessoal ou redução das penas - Acusados apanhados com 18 pinos de cocaína (11,23g) - Materialidade e autoria bem demonstradas - Testemunho de agentes policiais, sob o crivo do contraditório, ratificando a prova administrativa - Desclassificação para uso pessoal - Impossibilidade - Finalidade mercantil - Pena mínima reduzida de 1/6, nos termos do § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06, conformada a acusação nesse ponto - Regime fechado - Necessidade. Recursos não providos" (TJ-SP - APL: 00000565820148260417 SP 0000056-58.2014.8.26.0417, Relator: Ivan Sartori, Data de Julgamento: 15/09/2015, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 21/09/2015).

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a acusação contida nesta ação penal movida pela Justiça Pública contra CAROLINE CRISTINE PAES PINTO e REGINALDO SANCHES, qualificados, respectivamente, às págs. 6 e 4, para o fim de: a)- CONDENAR, a primeira (Caroline Cristine) como incurso no art. 33, § 4º, da Lei, nº 11.343/2006, c. c. o art. 29, "caput", do Código Penal, à pena de 7 (sete) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 64 (sessenta e quatro) dias-multa, na proporção já mencionada, substituída, no entanto (somente a pena corporal), pelas penas restritivas de direitos de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo mesmo prazo da pena corporal, e prestação pecuniária em favor de entidade pública ou privada de destinação social local, no valor equivalente a um salário mínimo atual (valor fixado pelo Governo), e o segundo (Reginaldo), à de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, na mesma proporção; e b)- ABSOLVÊ-LOS da imputação do art. 35, "caput", da mesma Lei, absolvição que faço com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Condeno os acusados, ainda, ao pagamento do valor equivalente a 100 (cem) "UFESPs" (Lei Estadual nº 11.608, de 29/12/2003), observado, no entanto, caso a defesa tenha sido feita por defensor dativo, o disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, aplicado analogicamente (CPP, art. 3º); o art. 12, da Lei nº 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, foi expressamente revogado pelo art. 1.072, III, do Diploma Processual Civil.

O acusado permanecerá em prisão domiciliar até o trânsito em julgado, salvo determinação em sentido contrário do E. Tribunal em caso de recurso.

Havendo descumprimento injustificado das penas restritivas de direitos ora fixadas, por parte da acusada, serão elas convertidas em privativa de liberdade (no caso a inicialmente estabelecida nesta sentença).

Decreto a perda, em favor da União, de todo o valor apreendido e depositado nos autos (referente a dinheiro), nos moldes do art. 63, § 1º, da Lei sobredita.

Já houve autorização para destruição das drogas (págs. 59/60).

Com o trânsito em julgado, providenciem-se as anotações e comunicações de praxe, inclusive à Justiça Eleitoral, bem como a transferência do valor depositado em Juízo ao "Funad" (Lei nº 11.343/2006, art. 62, § 9º); e oficie-se à D. Autoridade Policial autorizando a destruição do restante da droga armazenado para eventual contraprova.

A inscrição do nome do acusado no rol dos culpados foi abolida pelas Normas de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça deste Estado (art. 372, "caput"). A expedição de mandado de prisão, em relação ao acusado, dar-se-á oportunamente (se necessário).

Na hipótese de a acusada se encontrar presa, ainda que por outro processo, oficie-se ao estabelecimento prisional respectivo, independentemente de trânsito em julgado, solicitando a disponibilização de tratamento adequado a ela (ante o teor do laudo pericial de págs. 410/412, que constatou a existência de dependência química), nos moldes do art. 47, c. c. o art. 26, ambos da mesma Lei, devendo o ofício ser instruído com cópias desta sentença e do referido laudo).

Expeça-se guia de execução provisória em relação ao acusado (prisão domiciliar), com urgência e prioridade.

P. I. C.

Catanduva, 9 de março de 2022.

ANTONIO CARLOS PINHEIRO DE FREITAS
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA